



**Unidad Administrativa Especial Agencia del
Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales-ITRC**

DEBIDO PROCESO/CONSTITUCIÓN POLÍTICA ARTÍCULO 29

Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.

DEBIDO PROCESO /SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

Principio inherente al Estado de Derecho, cuyas características esenciales son el ejercicio de funciones bajo parámetros normativos previamente establecidos y la erradicación de la arbitrariedad

DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO/ SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL

La jurisprudencia constitucional ha diferenciado entre las garantías previas y posteriores que implica el derecho al debido proceso en materia administrativa. Las garantías mínimas previas se relacionan con aquellas garantías mínimas que necesariamente deben cobijar la expedición y ejecución de cualquier acto o procedimiento administrativo, tales como el acceso libre y en condiciones de igualdad a la justicia, el juez natural, el derecho de defensa, la razonabilidad de los plazos y la imparcialidad, autonomía e independencia de los jueces, entre otras. De otro lado, las garantías mínimas posteriores se refieren a la posibilidad de cuestionar la validez jurídica de una decisión administrativa, mediante los recursos de la vía gubernativa y la jurisdicción contenciosa administrativa.

**EXTENSION DE GARANTIAS DEL DEBIDO PROCESO AL AMBITO ADMINISTRATIVO/
SENTENCIA CORTE CONSTITUCIONAL**

La extensión de las garantías del debido proceso al ámbito administrativo no implica, sin embargo, que su alcance sea idéntico en la administración de justicia y en el ejercicio de la función pública. A pesar de la importancia que tiene para el orden constitucional la vigencia del debido proceso en todos los escenarios en los que el ciudadano puede ver afectados sus derechos por actuaciones públicas (sin importar de qué rama provienen), es necesario que la interpretación de las garantías que lo componen tome en consideración los principios que caracterizan cada escenario, así como las diferencias que existen entre ellos.¹

¹ Sentencia C-034/14



POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

Dependencia:	Subdirección de Investigaciones Disciplinarias
Número del Proceso:	1704-01-2012-072
Número y fecha del fallo:	RESOLUCIÓN No. 17317-00006 22 de marzo de 2017
Asunto:	Fallo de primera instancia
Criterio de Selección:	Fallo absolutorio de primera instancia

RESOLUCIÓN No. 17317-00006 22 de marzo de 2017

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

1. OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Una vez concluida la investigación disciplinaria tramitada en el proceso administrativo disciplinario número 1704-01-2012-072, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, procede a proferir fallo de primera instancia, conforme a las exigencias del artículo 170 de la Ley 734 de 2002 y de acuerdo a lo que sigue.

2. IDENTIDAD DEL INVESTIGADO

XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXX, quien ingresó a la DIAN el 27 de septiembre de 1995 y para la fecha de los hechos materia de investigación (diciembre de 2011 a marzo de 2012), se desempeñó como funcionario de planta en el cargo de Gestor III Código 303 Grado 03, en la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, como Jefe de la misma.

XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXX, quien ingresó a la DIAN el 28 de junio de 2011 y para la fecha de los hechos materia de investigación (diciembre de 2011 a marzo de 2012), se desempeñó como funcionario supernumerario (2011) y como empleado planta temporal (2012), en el cargo de Facilitador IV Código 104 Grado 04, en la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXX, quien ingresó a la DIAN el 4 de julio de 2013 y para la fecha de los hechos materia de investigación (diciembre de 2011 hasta 30 de enero de 2012), se desempeñó como funcionario de planta en el cargo de Analista II Código 202 Grado 02, en la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá.

3. HECHOS

1. La presente actuación se inició por la denuncia que el señor XXXXX, entonces gerente de la sucursal Bogotá de la empresa XXXXX, presentó el día 23 de marzo de 2012 ante el Director General de la DIAN, por la supuesta demora y el hurto parcial de algunos bienes ocurridos durante el procedimiento de aprehensión de la Guía Máster No. 233-6077- 6612, que fue inmovilizada por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá mediante Acta de Hechos No. 026372 de 17 de diciembre de 2011, con 6 bultos y 2.773 kilos, y dentro del cual ocurrieron las siguientes actuaciones:

- (i) el 19 de diciembre de 2011, el señor XXXXX solicitó al señor XXXXX, entonces Jefe de la División de Gestión Control Carga, el reembarque de la mercancía o el cambio de modalidad voluntario.
- (ii) El 27 de diciembre de 2011, el señor XXXXX respondió a aquel que el acta de aprehensión no estaba lista por realización del inventario.
- (iii) El 4 de enero de 2012, el denunciante solicitó la revisión de la actuación mediante derecho de petición.
- (iv) El 11 de enero de 2012, el quejoso fue de nuevo informado que el acta de aprehensión no estaba lista.
- (v) El 27 de enero de 2012, con Acta de Hechos No. 000714, se aprehendieron 2 cajas adicionales que habían sido olvidadas.
- (vi) El 6 de febrero de 2012, el señor XXXXX solicitó nuevamente el acta de aprehensión.
- (vii) El 8 de febrero de 2012, el señor XXXXX solicitó la intervención de la Procuraduría General de la Nación.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

- (viii) El 12 de febrero de 2012, de igual manera solicitó al señor XXXXX que le informara las razones y las normas en que basaba el procedimiento y la autorización para participar en la elaboración del acta de aprehensión e inventario.
- (ix) El 27 de febrero de 2012, el denunciante recibió el inventario de la mercancía dispuesta para aprehensión.
- (x) El 1 de marzo de 2012, el señor XXXXX envió escrito a la señora XXXXX, funcionaria de la misma División de Gestión Control Carga, con algunas observaciones sobre el faltante detectado en el inventario, para que determinara las responsabilidades y el valor de las mercancías perdidas.

No obstante, el denunciante XXXXX comentó que el funcionario XXXXX le ofreció la venta de una parte de la mercancía, quien adicionalmente le dijo que sí no la compraba, él ya tenía quien lo hiciera. Por eso, expresó que realizó labores de investigación con el Grupo de Piratería Terrestre de la DIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá desde el mes de marzo de 2012, gracias a las cuales encontró que parte de la mercancía había sido vendida a comerciantes de San Andresito por parte del señor XXXXX, quien la recibió del señor XXXXX, y le manifestó que compraba remates de mercancía en Almagrario o que se los entregaba directamente el señor XXXXX, entonces jefe de ese depósito, quien a su vez le expresó que algunas veces acordaba con funcionarios de la DIAN para sacar una parte de la carga y poder venderla a algunos contactos, como fue el caso del señor XXXXX. La mercancía que encontró fueron celulares BlackBerry, pistolas de juguete, cremas, extensiones para cabello y relojes.

Por otra parte, también relató que la Guía Máster No. 233-6077-6531 fue inmovilizada mediante Acta de Hechos No. 025859 de 7 de diciembre de 2011, con 3 bultos y 1.500 kilos, pero que mediante Acta de Hechos No. 026166 de 15 de diciembre de 2011, fueron movilizadas 1.040 kilos el 21 de diciembre siguiente para su nacionalización y aprehendidos 460 kilos; sin embargo, la misma tuvo inconsistencias en la totalidad de los elementos y en el peso de los mismos, razón por la cual, previa autorización del señor XXXXX, se realizó un re-inventario de la carga mediante Acta de Hechos No. 000692 del 26 de enero de 2012, que arrojó un peso de 390.5 kilos y no de 460 kilos, lo que llevó a que este funcionario profiriera el Acta Aclaratoria No. 03-007 de 27 de febrero de 2012, en la que justificó el re- inventario sin indicar en dónde estaban los 70 kilos faltantes.

2. A partir de lo anterior, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, mediante auto No. 1001- 231 de 31 de mayo de 2012 (folios 101 a 104), dispuso la apertura de indagación preliminar "en averiguación", con el objeto de alcanzar los fines contenidos en el artículo 150 de la Ley 734 de 2002 y más adelante, con auto No. 1047-241 de 21 de agosto de 2012 (folios 205 a 206), ordenó la remisión de la actuación disciplinaria a la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales, con fundamento en el Decreto Legislativo 4173 de 2011 y demás normas modificatorias, porque, en su sentir, los hechos investigados se adecuaban "presuntamente a conductas tipificadas como delito, como lo es la concusión tipificada en el artículo 404 del Código Penal en concordancia con el numeral 1 del artículo 48 del CDU".

3. Por su parte, esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, a través de auto No. 17401-028 de 28 de agosto de 2012 (folio 207) avocó el conocimiento del expediente y a continuación, mediante auto No. 17404-027 de 18 de diciembre de 2012 (folios 243 a 245), dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los servidores XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX y XXXXX, por las posibles irregularidades acaecidas durante el procedimiento de aprehensión de las Guías Máster Nos. 233-6077-6612, 233-6077-6531 y 906-1011-8080, en especial, las relativas al hurto de algunos bienes, el posible incumplimiento de los términos establecidos en el Estatuto Aduanero para el reconocimiento e inventario de la mercancía y la elaboración de inventarios con un peso no correspondiente con la realidad; situaciones que pudieron dar lugar, entre otros, a los delitos de "Prevaricato por Omisión y de Falsedad Ideológica en Documento Privado".

Más tarde, con auto No. 17410-021 de 14 de abril de 2014 (folio 1007), este Despacho dispuso el cierre de la investigación disciplinaria con fundamento en el artículo 160A de la Ley 734 de 2002, al considerar que existía prueba para formular pliego de cargos.

finalmente, con auto No. 17417-00223 de 6 de mayo de 2015 (folios 1048 a 1053), no obstante la anterior decisión, ordenó la remisión de la actuación disciplinaria a la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, porque a partir del acervo probatorio recaudado concluyó que la "tardanza en expedir el acta de aprehensión parcial respecto de las Guías Máster Nos. 233-6077-6612 y 233-6077-6531, no constituye falta disciplinaria; que no se demostró que los sujetos procesales cometieron el hurto de algunos bienes pertenecientes a las mismas Guías Máster o que los hubieran vendido a algunos comerciantes de San Andresito; y que el señor XXXXX le ofreció al quejoso la venta de una parte de la carga aprehendida por valor de cien millones de pesos". Por lo tanto, se ordenó el envío de la causa a dicha Subdirección, para que determinara sí los bienes encontrados en San Andresito

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

obedeció al posible incumplimiento de un deber legal de los funcionarios que tenían su custodia y en ese evento, formulara cargos en su contra o en caso contrario, el archivo definitivo de las diligencias.

4. Sin embargo, la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través de auto No. 6003-67 de 23 de junio de 2015 (folios 1065 a 1068), propuso conflicto negativo de competencias administrativas porque en el precitado auto No. 17417-00223 de 6 de mayo de 2015, el Despacho no definió de fondo las conductas relativas al apoderamiento ilegal de ciertos bienes y a la mora en la aprehensión de la mercancía, a pesar de que en ambos casos afirmó su inexistencia, ni tampoco la presunta conducta constitutiva de los tipos penales de prevaricato por omisión y de falsedad ideológica en documento privado, los cuales fueron expuestos como motivo de acción disciplinaria en el auto de apertura de investigación No. 17404-027 de 18 de diciembre de 2012. Todas estas conductas, en su criterio, son de competencia de este Operador Disciplinario y deben ser falladas en el mismo proceso, dada la conexidad procesal y sustancial existente.

5. Finalmente, como ya se anticipó, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, a través de sentencia de fecha 10 de septiembre de 2015, radicado 11001-03-06- 000-2015-00119-0, consejero ponente Doctor XXXXX, conocida por este Despacho el día 30 de septiembre subsiguiente (folios 1150 a 1173), resolvió el conflicto negativo de competencias administrativas suscitado y en consecuencia asignó a esta Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, la competencia para continuar conociendo de la actuación disciplinaria "por lo menos hasta el momento de dictar pliego de cargos o de ordenar el archivo definitivo de la actuación". Ello porque la decisión que este Despacho adoptó de remitir el expediente a la DIAN, además de ser contradictoria porque expresó que no existía prueba de los hechos denunciados pero previamente estimó que existían pruebas suficientes para formular pliego de cargos y afirmó que no se demostró la apropiación indebida de bienes pero éstos igual fueron encontrados en el comercio informal de los "sanandresitos", solamente podía ser tomada después de proferir pliego de cargos en contra de todos, de algunos o de alguno de los investigados, toda vez que sería esa decisión y no otra, la que permitiría establecer la competencia y en el evento de que el Despacho imputara alguna falta disciplinaria de su competencia, debería "continuar con el proceso disciplinario hasta su terminación, pues resulta evidente que entre los diversos hechos referidos en la queja disciplinaria y las personas denunciadas en ese acto existe una clara conexidad sustancial y procesal".

4. CARGO FORMULADO

Por medio del Auto No. 17406-00010 del 7 de julio de 2016 la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos a los investigados XXXXX, XXXXX, XXXXX.

Los cargos disciplinarios formulados resultaron del siguiente tenor:

a). En relación con el señor XXXXX

CARGO PRIMERO: El señor XXXXX, con ocasión de sus funciones como Analista II Código 202 Grado 02 de la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 286 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), como quiera que extendió documento público ideológicamente falso, en cuanto consignó y firmó el Acta de Hechos No. 26166 de fecha 15 de diciembre de 2011 con una afirmación contraria a la verdad, consistente en que el peso de la mercancía que se movilizó con medida de prehensión, perteneciente a la Guía Máster No. 233-6077-6531, eran 460 Kg, cuando el peso real eran 390.5 Kg.

CARGO SEGUNDO: El señor XXXXX, con ocasión del cargo de Analista II Código 202 Grado 02 de la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y funcionario aprehensor de las Guías Máster Nos. 233-6077-6612 y 233-6077-6531, que arribaron al territorio aduanero nacional mediante la modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes, al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 50, como quiera que entre los meses de diciembre de 2011 y enero, febrero y marzo de 2012, ejecutó en provecho de terceros acciones tendientes a violar el régimen aduanero, en cuanto la parte de dicha mercancía que se encontraba en causal de aprehensión, debió aprehenderla conforme lo establecen los artículos 504, 505 y 506 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero) y artículo 5.2.3, 5.2.3.4 y 5.3 de la Orden Administrativa 003 de 2010 de la Dirección de Gestión de Fiscalización DIAN.

B) En relación con el señor XXXXX

CARGO ÚNICO: El señor XXXXX, en razón de su cargo de Gestor III Código 303 Grado 03 y Jefe de la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 417 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), como quiera que no denunció ante la autoridad correspondiente, la eventual falsedad

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

ideológica cometida por el funcionario XXXXX con la expedición del documento público denominado Acta de Hechos No. 026166 de fecha 15 de diciembre de 2011, en relación con la Guía Máster No. 233-6077- 6531, hecho del cual conoció, por lo menos, el 20 de febrero de 2012 cuando expidió el Acta Aclaratoria No. 5 de 20 de febrero de 2012, por medio de la cual se aclaró el Acta de Aprehesión No. 03-0007 COMEX.

C) En relación con el señor XXXXX

CARGO UNICO: El señor XXXXX, abusando de su condición de funcionario de la DIAN, ubicado en la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 404 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), como quiera que entre los meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012, le solicitó al señor XXXXX, entonces Gerente sucursal Bogotá de la empresa XXXXX, la suma de \$100.000.000 para devolverle parte de la mercancía perteneciente a la Guía Máster No. 233-6077-6612, que había sido inmovilizada por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá mediante Acta de Hechos No. 026372 de 17 de diciembre de 2011.

5. ARGUMENTOS DE DEFENSA:**VERSIÓN LIBRE, DESCARGOS Y ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

- Del señor XXXXX

El implicado no atendió la citación del Despacho para rendir versión libre y espontánea (folio 964), ni tampoco presentó algún escrito en ejercicio de su derecho de defensa.

DESCARGOS:

El apoderado del disciplinado presento el escrito de descargos dentro de los términos de ley, afirmando en el mismo, que su representado ha sido investigado en dos ocasiones por los mismos hechos y circunstancias por parte de la oficina disciplinaria de la DIAN y la ITRC, sobre dichos procesos afirmó que han finalizado en terminación de la investigación y en consecuente el archivo definitivo del proceso, correspondiendo a los números 213-303-2012 (DIAN) y 1704-01-2012-48 (ITRC).

Por tanto, adujo que se estaría en presencia de la vigencia del instituto jurídico de la cosa juzgada y/o del fenómeno de cosa juzgada, por tratarse de una consonancia univoca entre el objeto del proceso, o del aforismo latino non bis in ídem, es decir no se puede juzgar dos veces por lo mismo.

Indicó que los efectos de la cosa juzgada suceden en disposición de orden constitucional y legal que impiden reiniciar controversias finalizadas acorde con el desarrollo de la ritualidad procesal respectiva, pues el objeto de dicha garantía les imprime un valor definitivo e inalterable.

Que la hipótesis de que no se impongan duplicidad de sanciones en los casos que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento, en donde la justificación misma del Estado Social de Derecho, pasa, entre otros aspectos, por la sujeción de la actuación de sus autoridades a los principios de legalidad, objetividad y debida utilización de los recursos públicos y encierra el tradicional principio general del proceso, con un doble significado:

1. Impide que una persona sea sancionada o castigada dos veces por la misma infracción.
2. Principio procesal en virtud del cual un mismo hecho no puede ser objeto de dos procesos distintos (Fl. 1247 a 112).

ALEGATOS DE CONCLUSION

El implicado no presentó algún escrito de alegatos de conclusión.

- Del señor XXXXX

VERSION LIBRE

Rendida el 5 de marzo de 2014 (folios 950 a 955), explicó que para la fecha de los hechos era dispendiosa la labor de control por escases de personal, lo cual era de conocimiento del nivel central de la DIAN y en relación con el procedimiento adelantado, mencionó que se encontró diversidad de mercancía que no estaba relacionada en el documento de transporte, lo que generó su aprehensión y por lo mismo dificultades en el proceso de inventario y avalúo. Además, que no hubo demoras ilegales pues no existía un término para la aprehensión en zona primaria y que al interesado se le explicó que podía presentar una denuncia por la pérdida

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

de la mercancía, asunto que verificaron personalmente encontrando inconsistencias en el peso. Más adelante precisó que su intervención fue hasta la orden de inmovilización, que él no podía ordenar la devolución de la mercancía porque el interesado debía agotar la vía gubernativa y que desconocía el hallazgo de parte de la mercancía en el comercio del San Andresito.

DESCARGOS:

Mediante apoderada judicial, presentó dentro de los términos de Ley el escrito de descargos, en donde adujo que se le endilga a su representado el haberse abstenido "INTENCIONALMENTE" de denunciar una presunta falsedad ideológica en documento público por parte del funcionario XXXXX.

En relación con este hecho trajo a colación lo manifestado en diferentes jurisprudencias así:

"...(i) un servidor público tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible; que (ii) la investigación de dicha conducta punible deba iniciarse de oficio, y, que (iii) el servidor público que ha tenido conocimiento de la conducta punible, ha omitido ponerla en conocimiento de la autoridad competente .

Se trata entonces de un tipo de omisión, toda vez que cuestiona al servidor público el incumplimiento del deber de denunciar la conducta punible investigable de oficio, de cual tenga conocimiento.

Dicha norma sanciona la conducta de quien desconoce el mandato contenido en el artículo 27 del C. de P. Penal, inciso 2 (artículo 67 de la Ley 906 de 2004), según la cual "El servidor público que por cualquier medio conozca de la comisión de una conducta punible que deba investigarse de oficio, iniciara sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento de la autoridad competente".

No obstante, en consideración al bien jurídico tutelado, esto es, el del correcto funcionamiento de la administración pública, debe entenderse que la obligación de denunciar recae en el servidor público cuando éste tenga conocimiento cierto de la comisión de una conducta punible, o por lo menos el convencimiento serio y fundado de su ocurrencia, pues una actitud precipitada e irreflexiva podría terminar vulnerando precisamente el bien jurídico tutelaron (SyNFT).

Resulta indudable que presentar denuncias sin formula de juicio, sustentadas en meras suposiciones o comentarios, generaría un desgaste innecesario para la administración de justicia y terminaría afectando su eficiencia y Eficacia .

Como también el concepto con destino a la comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representas por parte de Procuraduría General de la Nación:

"Otra cosa en la responsabilidad penal que pueda recaer en el ex mandatario, pues para imputarle, por ejemplo, la conducta de abuso de autoridad por omisión de denuncia (Art. 417C.P.)m, que se presenta cuando el servidor público conoce de la comisión de una conducta punible cuya averiguación se debe iniciar de oficio y no la denuncia, se requiere, en primer lugar, que ese servidor público tenga el convencimiento de que se trata de una conducta punible que tiene el deber de denunciar, conforme lo demanda también el artículo 27 del C.P.P. y de que tiene la información seria, conducente y fundada sobre la comisión de un delito .

Con la información antes descrita, se dispuso a indicar que su prohijado no incurrió objetivamente en la conducta de abuso de autoridad por omisión de denuncia, ya que, en el momento de la diferencia de peso en el acta, se acreció de elementos de juicios suficientes para concluir que la discrepancia de valores se considerara como una maniobra que engañosa o destinada a la apropiación de bienes.

Por tanto, era válido que su representado no formulara denuncia penal alguna por la comisión de un punible de falsedad ideología en documento público, puesto que no se tenía conocimiento serio y fundado, que concluyera que la diferencia de peso en el acta fuera un actuar desleal del funcionario XXXXX o por el contrario de un accionar reprochable de un empleado director de Almagrario.

Ahora, adujo la apoderada, que en procura del esclarecimiento de los hechos y con el propósito que sé determinara por autoridad competente la posibilidad de haberse incurrido en alguna irregularidad, con repercusiones penales o disciplinarias, mediante los oficios N. 1-03-246-201-177 de 22 de febrero de 2012 y 01-03-201-00025 del 19 de abril de 2012, su representado puso en conocimiento de la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, los hechos relacionados con las guías master 233-6077-6531 y 233-607706612, con el propósito que se realizaran actividades probatorias pertinentes, conducentes y útiles, para disponer (denuncia penal y/o proceso disciplinario).

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

Con los argumentos expuestos la representante del disciplinado XXXXX, afirmó que éste no incurrió en la conducta disciplinaria gravísima imputada en el auto de pliego de cargos del 7 de julio de 2016, por tanto, requiere se absuelva de la misma (Fl. 1372 a 1387).

ALEGATOS DE CONCLUSION

Presentados por la apoderada del aquí investigado dentro de los términos de Ley, en el escrito reitera las aseveraciones realizadas en los descargos elevados ante este despacho, recalcando:

Que se libraron los oficios N. 1-03-246-201-177 del 22 de febrero de 2012 y 01-03-201-00025 del 10 de abril de 2012, mediante los cuales se informó a la Subdirección de Gestión de Control Interno Disciplinario de la DIAN, los hechos atinentes a las guías master N. 233-6077-6531 y 233-607706612, para que fuera determinada la ocurrencia de una conducta disciplinaria, o de ser el caso compulsar a la Fiscalía General de la Nación.

Que dichos soportes fueron anexados en el escrito de descargos, por tanto, la omisión endilgada a su representado pierde el asidero una vez se trasladan a la autoridad competente los hechos, como en el presente caso.

Solicita se absuelva de responsabilidad disciplinaria a su representado y se declare la terminación del proceso disciplinario (Fl. 1578 a 1581).

- Del señor XXXXX

Por intermedio de apoderado, mediante escrito presentado el 18 de marzo de 2013 (folios 296 a 304), además de una solicitud probatoria, transcribió algunos apartes de la queja disciplinaria relativos a la solicitud indebida de dinero y a los operativos realizados por el quejoso, para expresar que a éste nada le interesa el imperio de la Ley sino para su propio beneficio y para "pisotear las ritualidades establecidas en las normas procedimentales" a fin de producir hechos inexistentes, conducta con la cual, adicionalmente, provocó que los miembros de la Policía Nacional quebrantaran el código de ética contenido en el "Reglamento de Vigilancia Urbana y Rural para la Policía Nacional" (Resolución 9960 de 1992).

Más adelante, a través de escrito presentado el 2 de abril de 2013 (folios 314 a 338), el apoderado también solicitó la práctica de otras pruebas y a continuación transcribió algunos apartes de la queja disciplinaria relacionados con los operativos que el quejoso realizó con apoyo de la SIJIN, los cuales replicó señalando que, en su sentir, se presentaron múltiples irregularidades relacionadas con la confesión lograda a los señores XXXXX y XXXXX, el allanamiento a la vivienda del primero de éstos, la realización de allanamientos y entrevistas grabadas, y la no elaboración de la cadena de custodia sobre los bienes devueltos.

El mismo 2 de abril de 2013, el defensor presentó otra solicitud de pruebas tendientes a demostrar el irregular proceder del quejoso en los procedimientos realizados con apoyo del Grupo de Piratería Terrestre de la SIJIN, en los cuales, a su modo de ver, abusó de su calidad de Oficial en Retiro de la Policía Nacional. Además, allegó una serie de documentos noticiosos y periodísticos en los cuales se evidencia el posible actuar irregular de algunos miembros de la Policía Nacional (folios 360 a 383).

Finalmente, mediante escrito presentado el 2 de mayo de 2014 (folios 1012 a 1028), el defensor alegó que no se probó la reunión entre el quejoso y su defendido, y por lo tanto del requerimiento de dinero; que no se aportó la grabación demostrativa de la supuesta "componenda", la cual, de existir, estaría marcada de ilegalidad; y que el testimonio del quejoso "no es digno de valor probatorio" porque genera duda sobre su credibilidad y seriedad y porque está desacreditado por otros testimonios. A continuación, refirió que el señor XXXXX, cuando presentó la queja ante la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Administrativa, nada dijo sobre el requerimiento de dinero, pero que, con su testimonio, precisó la suma de dinero solicitada y además involucró a más funcionarios y reconoció que los señores Alfonso Castro Flórez y Sergio Bonell, en ningún momento hicieron la imputación de conocer la propuesta de dinero y por el contrario, estuvieron sumidos en una situación de "temor, aprensión y desconfianza", producto de un elemento extraño. Finalmente, en relación con el debido proceso, hizo referencia a algunas sentencias de la Corte Constitucional y de normas de alcance internacional, y luego hizo un análisis sobre la valoración de la prueba.

DESCARGOS

Por medio de su apoderado presento escrito de descargos dentro de los términos de Ley, en donde respecto al cargo endilgado, sobre la solicitud realizada al quejoso de la suma de \$100.000.00, a cambio de devolverle parte de la mercancía que le había sido inmovilizada por la DIAN mediante acta de hechos 026372 del 17 de diciembre de 2011, afirmó:

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

Que funda la oposición frente a la pretensión disciplinaria, en la actividad probatoria, teniendo en cuenta que observa falencias en la misma que afectan la integridad y probidad del señalamiento.

Respecto a los hechos señalados en el escrito de queja del señor XXXXX, adujo que los mismos no sucedieron, y que se debe considerar que el quejoso era el interesado en sacar adelante una situación irregular de ingreso de mercancías al territorio nacional, por tanto, el quejoso debería entenderse como un testigo sospechoso y realizar un análisis con particular cuidado de sus escritos, y más aún cuando las actuaciones de los funcionarios de la DIAN, generaron sanciones y fueron confirmadas en los procesos subsiguientes en la división de gestión jurídica, demostrando el correcto actuar de la entidad.

Indicó que la ITRC, no realizó pronunciamiento alguno sobre el tipo de actividad que el quejoso pretendía desarrollar al ingresar al territorio nacional multitud de mercancías, sin el cumplimiento de los requisitos legales.

Como tampoco la unidad se refirió a la actividad ilegal que al parecer desarrollo el quejoso, cuando dispuso allanamientos y retenciones ilegales a comerciantes, como tampoco se mencionó el ofrecimiento por parte del quejoso de aportar videos, grabaciones y documentos de importancia, los cuales nunca allego a la investigación disciplinaria.

De igual manera, afirmó que tampoco se analizó la actitud desleal del quejoso, a quien se citó en cinco ocasiones y nunca se hizo presente y no ha sido posible contactar, demostrando que dicha queja podría considerarse una queja infundada, teñida de temeridad y mala fe.

Que, por las actividades desplegadas por el señor quejoso, se demuestra que al no obtener los resultados requeridos con los operativos ilegales, señalamientos malintencionados, amenazas, procedió a tapar sus faltas y a satisfacer sus apetitos de venganza, optando por no comparecer más a la actuación disciplinaria presumiendo que el daño ya estaba hecho.

Respecto a la declaración jurada rendida por el aquí quejoso, afirmó que la misma vulnera el derecho de defensa, ya que para la época que fue tomada por el operador disciplinario, ya se tenían identificados a los procesados y en consecuencia debieron ser citados a su práctica conforme dispone el artículo 92.4 del CDU, a efectos de hacer valer sus derechos.

Sobre las declaraciones de los señores XXXXX y XXXXX, comentó que estas no fueron analizadas en el pliego de cargos ya que los mismos manifestaron que no conocían al señor XXXXX, y respecto al señor XXXXX adujo que este indico no haber observado que su representado hablara con el quejoso, lo que tampoco fue estudiado por el despacho, siendo esta una información que desvirtúa la afirmación temeraria del señor XXXXX quien pretendió enlodar a su prohijado.

Otro punto que menciona sobre la información errada dada por el quejoso y no valorada por la ITRC, es el oficio de la Policía Nacional, Metropolitana de Bogotá, mediante el cual indican que no han adelantado procedimientos policiales en antipiratería terrestre en la época señalada por el quejoso, ni haber colaborado ni involucrado a los señores XXXXX y XXXXX.

Considera desproporcionado hacer un señalamiento de responsabilidad fundado exclusivamente en la queja y su ampliación jurada, sin considerar la posición viciada del quejoso, el haberse abstenido de comparecer al proceso a fin de someterse al escrutinio legal de los sujetos procesales, rompiendo con el principio de constitucional y legal de contradicción, el cual debió ser garantizado por el instructor de la agencia, siendo la queja y ampliación el único sustento en el que se basa la conducta endilgada a su representado (Fl. 1282 a 1295).

ALEGATOS DE CONCLUSION

Presentados por el apoderado del disciplinado dentro de los términos de Ley, manifiesta su descontento por la actuación de la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, ya que ha desconocido las garantías de su representado.

Resalta que la ITRC, en especial la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias, ha sido "incapaz" de practicar la prueba solicitada por la defensa, que es la única prueba que dice algo de fondo del asunto, vulnerando el derecho de contradicción del disciplinado.

De igual manera, que el 3 de agosto de 2016, solicitó se fijara fecha y hora para la versión libre de su representado, sin que se hubiera fijado la misma a la fecha de la presentación de los descargos; aunado que

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

la ITRC respecto a la responsabilidad de su representado siempre ha tenido posturas contradictorias y disimiles.

Adujó que la conducta renuente, el sarcasmo o burla que ha desplegado el quejoso XXXXX, contra la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias UAE ITRC, y contra los investigados, sin temor a equívocos le resta credibilidad, veracidad y valor probatorio a la declaración jurada rendida el 13 de agosto de 2012.

Por tanto, el operador disciplinario no puede desconocer, que estamos frente a un actuar irregular del quejoso, al no comparecer a la práctica de la prueba, rehusando en forma

sospechosa a presentarse, convirtiendo sus señalamientos en indefinidos. Es decir, en afirmaciones sin posibilidad de prueba, pues no se encuentra sustento probatorio.

Manifiesta que espera que atendiendo los principios de proporcionalidad, duda razonable, ponderación y razonabilidad, se adopte la decisión que corresponda a una verdadera administración de justicia disciplinaria, como lo es la terminación del proceso disciplinario y/o archivo definitivo a favor de su prohiado al no existir ninguna prueba que señale responsabilidad al mismo (FL. 1569 a . 1577)

6. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA:**RAZONES DE LA DECISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS EN QUE SE BASA****6.1. MARCO JURÍDICO Y COMPETENCIA:**

Este Despacho es competente para proferir el fallo de primera instancia dentro de la presente investigación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 67 y 76 de la Ley 734 de 2002, en concordancia con las previsiones del Decreto 4173 del 3 de noviembre de 2011.

En atención a lo ordenado en el Artículo 142 de la Ley 734 de 2002, no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado, cuya apreciación debe corresponder a las reglas de la sana crítica, según lo establece el Artículo 141 ibídem.

De igual manera, deben reunirse de manera conjunta los requisitos de legalidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, reglados en los artículos 4, 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, los cuales es menester se encuentren debidamente acreditados dentro del sumario a partir de elementos de prueba legalmente allegados al proceso.

6.2. DEL CASO EN CONCRETO

De la actuación procesal Frente al caso en particular la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN inició apertura de indagación preliminar mediante auto no. 1001-231 del 31 de mayo de 2012, dicha subdirección remitió por competencia el proceso a la Agencia del Inspector General de Tributos Rentas y Contribuciones Parafiscales, avocando conocimiento el día 28 de agosto de 2012.

Con auto No. 17404-027 de 18 de diciembre de 2012 (folios 243 a 245), dispuso la apertura de investigación disciplinaria y con auto No. 17406-00010 del 7 de julio de 2016 la Subdirección de Investigaciones Disciplinarias de la UAE ITRC, formuló pliego de cargos a los señores XXXXX, XXXXX u XXXXX y termino el proceso para los otros investigados.

Dentro de términos legales, los apoderados presentaron los correspondientes descargos, una vez practicadas las pruebas en descargos, corriendo entonces traslado para alegatos, vencido el término este despacho entrará a valorar el material probatorio allegado a la presente instrucción disciplinaria, conforme las reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica, a efectos de adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda. A continuación, se hará una relación sucinta y concreta de las pruebas relevantes que se analizarán para tomar la decisión de fondo dentro del presente radicado.

De las pruebas y su valoración

DOCUMENTALES

Antecedentes de los hechos denunciados, así:

- a) En relación con la Guía Máster 233-6077-6612:
 - Acta de hechos No. 26372 de fecha 17 de diciembre de 2011, suscrita por el funcionario "Francisco Urrego", por medio de la cual se dispuso su inmovilización (folios 18 y 128

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

- Acta de hechos No. 267 de fecha 18 de enero de 2012, suscrita por el funcionario "Camilo Durán C.", por medio de la cual se movilizaron en aprehensión 2356 Kg "por no encontrarse descrita en el documento de transporte" y se movilizaron para continuar trámite aduanero 423 Kg (folios 19 y 129).
- Acta de hechos No. 714 de fecha 27 de enero de 2012, suscrita por el funcionario "Henry Moreno C.", por medio de la cual se movilizaron en aprehensión 2 cajas adicionales con un peso de 57 Kg. (folio 20).
- Actas de hechos de reconocimientos de mercancías Nos. 763, 762 y 761 de fecha 31 de enero de 2012, suscritas por el funcionario "Henry Moreno C." (folios 26 a 29 y 130 a 132).
- Derecho de petición de fecha 4 de enero de 2012, radicado al día siguiente con número 000264, a través del cual el señor XXXXX, en su condición de representante legal de XXXXX., solicitó al entonces Director Seccional de Aduanas de Bogotá, la revisión de la actuación adelantada por la División de Gestión Control Carga, tendiente a obtener la entrega de la mercancía que, en su sentir, llevaba más de 20 días en verificación (folios 31 a 35 y 133 a 137).
- Oficio No. 01-03-201-000024 de fecha 17 de enero de 2012, suscrita por el funcionario "XXXXX- Director Seccional de Aduanas de Bogotá", mediante el cual se dio respuesta a la anterior petición en el sentido de que no procedía la entrega de la mercancía porque se encontraba en proceso de inventario para formalizar la medida cautelar de aprehensión (folios 36 a 37 y 138 a 139).
- Escrito de fecha 8 de febrero de 2012, radicado el día 10 siguiente, mediante el cual el señor XXXXX solicitó al Procurador General de la Nación su intervención dentro del procedimiento adelantado por la División Control Carga (folios 67 a 69).
- Derecho de petición radicado número 002569 de fecha 12 de febrero de 2012, a través del cual el señor XXXXX solicitó al funcionario XXXXX, entonces Jefe de la División Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, el fundamento jurídico y procedimental por medio del cual se ha mantenido la mercancía bajo una dilación de más de 55 días (folios 38 a 41 y 140 a 143).
- Oficio No. 01-03-246-201-191 de fecha 22 de febrero de 2012, suscrita por el funcionario "XXXXX", a través del cual dio respuesta a la anterior petición, en el sentido de detallar el procedimiento adelantado frente a la mercancía y la organización de la División, aclarando que el proceso de aprehensión tiene en cuenta las características y cantidades de la mercancía y la capacidad operativa de la dependencia. Con todo, que la mercancía del asunto se encuentra en proceso de aprehensión (folios 42 a 43 y 144 a 145).
- Solicitud de fecha 12 de febrero de 2012, suscrita por el señor XXXXX, Jefe de Logística de XXXXX, respecto de copia del Acta de Aprehensión y su correspondiente inventario (folios 45 a 146).
- Oficio No. 01-03-246-201-186 de fecha 24 de febrero de 2012, suscrito por la funcionaria "XXXXX—Despacho División de Gestión Control Carga", mediante el cual remitió fotocopia del inventario de la mercancía dispuesta para aprehensión, en respuesta a la anterior solicitud (folios 46 a 66 y 147 a 167).
- Escrito de fecha 1 de marzo de 2012, radicado el día 12 siguiente con el número 4930, con el cual el señor XXXXX reportó a la funcionaria XXXXX.

Borda, un faltante de mercancías y unas precisiones en cuanto a cantidades y pesos, de acuerdo con el inventario remitido por ella respecto de las facturas que amparaban las mercancías (folios 70 a 79 y 168 a 177).

- Oficio No. 1-03-246-201-306 de fecha 22 de marzo de 2012, suscrito por el funcionario "XXXXX", a través del cual dio respuesta al anterior escrito, en el que informó que la factura no evidencia que el total de la mercancía amparada arribó al territorio aduanero; que dentro de las facultades de la DIAN se encuentra el proceso de reconocimiento de mercancías, en el cual corresponde verificar peso, bultos y descripción, frente a lo manifestado por el sistema MUISCA; y que en el caso en concreto, la mercancía se encontraba en proceso de aprehensión debido a las características y cantidades (folio 178).

b) En relación con la Guía Máster 233-6077-6531:

- Acta de Hechos No. 25859 de fecha 7 de diciembre de 2011, suscrita por la funcionaria "Sandra Moreno", por medio de la cual se dispuso su inmovilización (folios 80 y 180)
- Acta de Hechos No. 26166 de 15 de diciembre de 2011, suscrita por el funcionario "Camilo Duran C." por medio de la cual se movilizaron en aprehensión 460 Kg. "por no encontrarse la mercancía descrita en el documento de transporte" y se movilizaron para continuar trámite aduanero 1042 Kg. (folios 81 y 181).
- Acta de Aprehensión No. 03-0007 COMEX de 11 de enero de 2012, suscrita por el funcionario "Emigdio Camilo Duran" (folios 184 a 188).
- Acta de Hechos No. 692 de 16 de enero de 2012, suscrita por el funcionario XXXXX, a través de la cual se procedió a revisar nuevamente el peso y cantidades de la mercancía aprehendida,

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

encontrando un peso total de 390 Kg y por lo tanto una diferencia de 50 Kg., y además se registró que "tras conteo rápido... se evidencia que hay más cantidades que las relacionadas en inventario y Acta de Aprehensión No. 007 del 11 de enero del 2012" (folios 82 y 182).

- Acta Aclaratoria No. 5 de 20 de febrero de 2012, suscrita por los funcionarios XXXXX-funcionario aprehensor" y "XXXXX Jefe de División", a través de la cual se aclaró el Acta de Aprehensión No. 03-0007 COMEX (folios 89 a 90 y 189 a 190).

- Escrito de fecha 14 de marzo de 2012, radicado al día siguiente con el número 316, con el cual el señor XXXXX- Represente Legal de la sociedad Coindecol Ltda., objetó el acta de aprehensión No. 003-0007 XXXXX y el Acta Aclaratoria No. 5 de 20 de febrero de 2012, porque en su criterio no se configuró la causal de aprehensión, además de advertir que la mercancía no llegó completa al depósito (folios 91 a 92 y 191 a 193).

2) Extractos de historia laboral de los sujetos procesales por el periodo 2011 a 2013 y certificado de salarios y deducciones por el periodo junio de 2011 a julio de 2013 (folios 574 a 597 y 600 a 666).

3) Oficio No. 100211231-de fecha 4 de diciembre de 2012, a través del cual la Subdirección de Gestión de Fiscalización Aduanera de la DIAN respondió requerimiento de este Despacho en los siguientes términos (folios 233 a 237):

"...me permito informarle que el inciso segundo del artículo 504 del Decreto 2685 de 1999 en concordancia con lo preceptuado en el artículo 432 de la Resolución 4240 de 2000, con sus modificaciones, contempla que establecida la configuración de alguna de las causales de aprehensión y decomiso de mercancías de que trata el artículo 502 del decreto 2685 de 1999, la autoridad aduanera expedirá un acta con la que se inicia el proceso para definir la situación jurídica de mercancías.

"En ese sentido, conforme a lo requerido en su oficio me permito remitirle la Instrucción Administrativa No. 00014 de 20 de octubre de 2006 del Director General de Impuestos y Aduanas Nacionales, por la cual se establecen las pautas, que deben tener en cuenta los funcionarios de las Divisiones de Fiscalización Aduanera, Fiscalización Tributaria y Aduanera y miembros de la Policía Fiscal y Aduanera, en la realización de acciones de control aduanero, la cual señala en el párrafo segundo del numeral 7.3 que el funcionario aduanero con base en los hechos expuestos en el Acta de Retención mencionada en el párrafo primero de la citada Instrucción Administrativa, evaluará si procede o no aplicar la medida cautelar a que haya lugar, dentro del día siguiente (24) horas al momento en que sean puestas a disposición del área de fiscalización".

4) Respuesta de la SIJIN- Policía Metropolitana de Bogotá, Oficio No. 104287/SIJINGRUPE-29-25 de 2 de julio de 2013, en la que informó que no se encontró registro de algún tipo de procedimiento judicial que funcionarios del Grupo Antipiratería Terrestre o de Investigaciones Generales, hubieran realizado en los meses de febrero y marzo del año 2012 en la Carrera 55 No. 22-60 de Bogotá, o que involucraran a los señores XXXXX y XXXXX, o que hubiese sido colaboración al señor XXXXX (folio 667).

5) Calidad de ex servidor de la Policía Nacional del quejoso XXXXX, en la que se observa que se retiró del servicio activo en el grado de TC (Teniente Coronel) con fecha 3 de marzo de 2009 (folios 748 a 755).

6) Oficio 1-03-246-201-177 del 20 de febrero de 2012, suscrito por el señor XXXXX, Jefe de la División de Gestión de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, dirigió al doctor XXXXX, Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno, en donde da a conocer las presuntas irregularidades relacionadas con la guía master 233-60776531, dentro estas la mercancía no relacionada y las presuntas irregularidades en el peso de la misma, mencionando al funcionario XXXXX (folios 1394 a 1395).

7) Informe de aprehensión 03-007, en donde se refleja el inventario realizado el 26 de enero de 2012, teniendo en cuenta la queja verbal, relacionado con el acta de hechos 26166 del 15 de diciembre de 2011, encontrando que respecto a las lociones bronceadoras marca Pnemon, loción bronceadora en sobre de 200ml MARCA HF, Bisutería para el cabello sin marca, calculadora grafica HP 50G, Traductor diccionario marca Franklin, Jean para dama marca clasic sashion, mp3 marca titan, se encontraron mayores cantidades que las que se encuentran en el acta de aprehensión y las cuales deben ser objeto de la misma medida cautelar.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

Respecto al zapato para dama marca seisen no se encontró nada sobre este ítem (Fl. 1396 a 1397).

8) Auto N. 1017-240 del 18 de septiembre de 2012, por medio del cual se ordena la terminación y consecuente archivo de la investigación dentro del expediente administrativo disciplinario N. 213-303-2012-160, en contra del funcionario XXXXX, la cual se había originado con ocasión del informe presentado por el doctor XXXXX, por los hechos irregulares relacionados con el acta de aprehensión 03-007 COMEX del 11 de enero de 2012, en relación con la diferencia existente entre el peso de la mercancía aprehendida con el que se relaciona en el inventario realizado por el funcionario aprehensor XXXXX.

Las consideraciones del auto mencionado, se basan en indicar que la diferencia del peso de la mercancía, corresponde a un error aritmético cometido por el señor XXXXX cuando realiza el acta de hechos 26166 del 15 de diciembre de 2011, ya que el interesado afirmó en diligencia de reinventario que la mercancía inspeccionada estaba completa, aunado que el investigado afirmó que la diferencia de peso podía imputarse al peso de las estibas con soporte de madera en que llega la mercancía la primera vez que se pesa, la cual podía ser de 10 kg por cada una de ellas (folios 1407 a 1410).

9) Auto 17404-009 del 19 de diciembre de 2012, de la Unidad Administrativa Especial Agencia del inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, por medio del cual se ordena la terminación y consecuente archivo de la investigación dentro del expediente administrativo disciplinario N.1704-01-2012-48, en contra del funcionario XXXXX, el cual se había originado con ocasión del informe presentado por el doctor XXXXX, por los hechos irregulares relacionados con el acta de aprehensión 03-007 y otra, de la división de gestión control carga, por la diferencia existente entre el peso de la mercancía aprehendida con el que se relaciona en el reinventario.

Las consideraciones del auto mencionado, se basan en indicar que respecto a los hechos del acta de aprehensión 03-007, el mismo ya había sido investigado por la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, habiendo finalizado con terminación de la actuación, con llevando a archivar la actuación o incurrirían en cosa juzgada (Fl. 1260 a 1270).

- Formulario del Registro Único Tributario del señor XXXXX, en donde se registra la dirección avenida 19 N. 57C-07 Medellín (Fl. 1451).
- Constancia del 28 de octubre de 2016, en donde se indica que se llamó al número 4538947 de Medellín el cual aparecía en el RUT del señor XXXXX, pero no se registra como válido (Fl. 1452).
- Constancia del 31 de octubre de 2016, en la misma se plasma que esta unidad realizó las siguientes validaciones con relación a la ubicación del quejoso XXXXX, con el propósito de escucharlo en diligencia de testimonio:

-Comunicación con abonado telefónico 6601755 con coordenadas avenida 5 norte N. 24a Norte-42 Cali, presuntamente de la empresa XXXXX, registrando el número telefónico como no valido.

-Comunicación con abonado telefónico 6657783 con coordenadas avenida 4 norte N. 47N-36 Cali, dirección de notificación informada en su escrito de queja por el señor XXXXX, en donde al realizar la correspondiente llamada manifiestan que funciona la empresa LQQC (lo que quiera Colombia), lugar donde tampoco laboraba el quejoso.

-Con relación a la carrera 106 N. 23-37 Fontibón Bogotá, la cual se registra también como dirección de notificación presuntamente de la empresa la empresa XXXXX, registrado el número telefónico como no valido, adicional a folio 226 obra constancia del 28 de noviembre de 2012, respecto a que la empresa XXXXX no funciona allí.

-Respecto a la carrera 7a N. 43-27 Medellín, se encuentra oficio 100-213-303-267 dirigido a esa ubicación, pero con sello de devolución de la empresa de correos certificado.

-Por último, sobre la dirección avenida 19 N. 57C-07 con abonado 4538941 Medellín, la cual aparece en el RUT del quejoso, dicho número telefónico genera marcación errada (Fl. 1454 a 1455).

- Constancia del 28 de octubre de 2016, expedida por esta unidad, en el cual se indica que, al presentarse la funcionaria de la ITRC a la dirección de la apoderada del quejoso, con el propósito de ubicar a su representado para la ampliación de queja, le fue informado que la abogada XXXXX, había fallecido desde el mes de junio de 2015, por lo tanto, no fue posible la ubicación actual del señor XXXXX (1456).
- Oficio 58491 suscrito por el doctor XXXXX, Coordinador del Grupo de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde informa que respecto al ciudadano XXXXX, tiene como dirección calle 57 13 20 Cali (Fl. 1464).

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

- Oficio 2016 XXXXX suscrito por el teniente XXXXX, Jefe de Información y Consulta Archivo General de la Policía Nacional, donde informa que reposa en sus archivos respecto al señor XXXXX, la dirección calle 57 N. 13E 39^ Barrio Primera de mayo Cali y teléfono 3154077 (Fl. 1540).
- Constancia de llamada telefónica realizada al 3150777 con el propósito de ubicar al señor XXXXX, en donde atiende el sobrino del mencionado y se entrega el número de la funcionaria de la ITRC, para que este devuelva la correspondiente llamada (F. 1541).
- Constancia del 13 de diciembre de 2016, relacionada con la llamada realizada por el señor XXXXX a la unidad, con el propósito de verificar los motivos por los cuales la agencia lo requería, una vez conoció los mismos indico llamar en las horas de la tarde para poder definir una fecha de la diligencia (Fl. 1542).
- Constancia del 16 y 19 de diciembre de 2016, de llamada telefónica realizada al XXXXX con el propósito de ubicar al señor XXXXX, sonando apagado y dejando el mensaje de voz con los datos de la funcionaria de la ITRC (Fl. 1543 y 1544).

TESTIMONIALES

1) Declaración juramentada del quejoso XXXXX en la que reiteró que el acta de aprehensión se expidió después de cuatro meses a la inmovilización; que ésta se notificó por edicto; que la mercancía estuvo dos meses y medio en las bodegas de la aerolínea, sin ser depósito habilitado; que luego la mercancía se trasladó al depósito de XXXXX sin acta de aprehensión; que se presentó faltante entre lo inmovilizado y la aprehendido; que el funcionario XXXXX le ofreció parte de la carga a cambio de \$100.000.000; que no se permitió su participación en el acta de aprehensión; y que la mercancía se encontró para la venta en San Andresito porque la entregó el señor XXXXX, empleado de XXXXX, quien manifestó que la recibió de algunos funcionarios de la DIAN con esa finalidad (folios 202 a 204).

2) Declaración juramentada de la señora XXXXX (comerciante de San Andresito) en la que confirmó que compró la misma mercancía que importó a través de XXXXX (relojes marca Osirock), cuyo dinero se lo reembolsó el señor XXXXXX; que no conoce a los señores XXXXX alias "XXXXX", XXXXX, XXXXX y XXXXX; y que no recibió una visita de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá en los meses de marzo y abril de 2012, sino que a ella hizo mención el señor XXXXX cuando habló con el señor que le vendió la mercancía, a quien tampoco conoció (folios 840 a 843).

3) Declaración juramentada del señor XXXXX (comerciante) en la que mencionó que la mercancía de remate que ha comprado desde el año 1985 en XXXXX, XXXXX y XXXXX, la ha vendido en San Andresito por intermedio de alias "CUSTON"; que un señor que se identificó como coronel le recamó una mercancía como suya, incluida una relojería que ya había intercambiado; que "XXXXX" es un revuelto de mercancía que no es hurtada; y que no conoce a los señores XXXXX, XXXXX y XXXXX (folios 846 a 853).

4) Declaración juramentada del señor XXXXX (entonces empleado de XXXXX) en la que expresó que conoció a los señores XXXXX, porque era comprador de mercancías en XXXXX y XXXXX, porque en el mes de marzo de 2012 lo abordó a la salida de XXXXX para hablarle de una mercancía aprehendida que debía recuperar y de cuya pérdida lo hizo responsable; y que la mercancía hallada en San Andresito que él supuestamente entregó, debió ser aquella que el señor XXXXX compró a XXXXX, pues desconoce qué mercancías se estaban comercializando y además, porque las cantidades que recibió fueron con las que se hicieron los DIAM. Más adelante explicó el procedimiento de entrega de mercancías a XXXXX y por qué se sintió coaccionado por parte del señor XXXXX (folios 854 a 861).

5) Declaración de la señora XXXXX (apoderada del quejoso) en la que relató brevemente el trámite aduanero que surtió la mercancía y explicó a continuación que, a raíz de la misma situación, su protegido debió liquidar la sociedad que tenía y asumir la pérdida de dinero. Además, que no tiene ni idea del supuesto operativo realizado por la SIJIN; que los documentos a los que alguna vez hizo mención en la Agencia ITRC, eran los derechos de petición y demás reclamaciones que hicieron durante el trámite, los cuales desconoce en manos de quién quedaron por terminación de la sociedad; y concluyó que este asunto ya no es de interés para su cliente (folios 942 a 945).

6. Declaración juramentada del señor XXXXX, quien para la época de los hechos laboraba en la división de gestión carga de la administración de aduanas Bogotá, teniendo como funciones inspección, reconocimiento y aprehensión de las mercancías.

Respecto a la mercancía aprehendida de XXXXX, para diciembre 2011, enero y febrero de 2012, afirmó que por orden del jefe XXXXX se puso al tanto de dicho trámite, por tanto, pudo conocer al representante legal de la empresa, es decir el señor XXXXX.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

Adujó que no tuvo contacto con el señor XXXXX, solo observo que el quejoso decía que la mercancía cumplía con los requisitos y que amenazaba a su jefe el doctor XXXXX, diciéndole que tendría problemas con abuso de autoridad. Indicó que mientras el proceso de aprehensión junto con su compañero XXXXX y otros, nunca se escuchó de algún ofrecimiento de dinero por parte del dueño de la mercancía, ni tampoco que su compañero haya pedido plata a dicho señor para entregarle la mercancía (Fl. 1482 a 1488).

INSPECCIÓN ADMINISTRATIVA

-A la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, en la que se obtuvo la impresión de algunos documentos de la plataforma MUISCA en relación con la Guía Máster 233-6077-6612 (folios 862 a 869 vto.).

-Continuando con la búsqueda del señor XXXXX, se realizó desplazamiento a las direcciones proporcionadas por el Registro Distrital de Conductores de Bogotá y por al Registraduría Nacional del Estado Civil, Calle 57 N-13-39/13-20 Cali encontrando que las nomenclaturas NO EXISTEN, adicional se indago a las personas vecinas si conocían al señor XXXXX, quien indicaron que no lo conocían (Fl. 1530 a 1532).

-Constancia del 11 de octubre de 2017, en donde se plasma que siendo citado a diligencia de declaración el señor XXXXX, en las instalaciones de la Dirección Seccional de Impuestos de Cali, la funcionaria de a la ITRC, se comunicó al celular 3183421798, donde fue atendida por el señor XXXXX, quien le indicó que no tenía conocimiento de la diligencia y estaba en Cartago, y le proporciono correo electrónico para las próximas notificaciones, de igual manera le manifestó que para una nueva fecha debería esperar hasta después de las 2:00pm o de lo contrario el despacho tomara la decisión correspondiente (Fl. 1554).

CONSIDERACIONES DE FONDO

Una vez evacuadas las pruebas que en etapa de descargos fueron decretadas por la instancia de conocimiento, como las que oficiosamente se consideraron pertinentes a cuenta del despacho, así como los traslados de ley, se tiene que el procedimiento disciplinario regido bajo los parámetros de la Ley 734 de 2002, tiene como finalidad la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho^ sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que intervienen. Por esta razón, se hace necesario valorar en conjunto las pruebas referidas en cada caso particular y concreto.

Teniendo en cuenta, el caudal probatorio allegado en fase preliminar y de investigación que soportó el escrito de acusación no se mantiene en sede de fallo por cuanto los elementos arribados en traslado de descargos generan serias dudas que atentan contra la firmeza de la acusación.

Por tanto, se procede a realizar las conductas endilgadas a cada uno de los investigados, para tener claridad sobre cada una de estas, así:

a). XXXXX

Respecto a este disciplinado, le fueron endilgados dos cargos,

- "(...) al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 1°, en armonía con el artículo 286 de la Ley 599 de 2000 (Código Penal), como quiera que extendió documento público ideológicamente falso, en cuanto consignó y firmó el Acta de Hechos No. 26166 de fecha 15 de diciembre de 2011 con una afirmación contraria a la verdad, consistente en que el peso de la mercancía que se movilizó con medida de aprehensión, perteneciente a la Guía Máster No. 233-6077-6531, eran 460 Kg, cuando el peso real eran 390.5 Kg"
- "(...) al parecer incurrió en la conducta descrita en la Ley 734 de 2002, artículo 48 numeral 50, como quiera que entre los meses de diciembre de 2011 y enero, febrero y marzo de 2012, ejecutó en provecho de terceros acciones tendientes a violar el régimen aduanero, en cuanto la parte de dicha mercancía que se encontraba en causal de aprehensión, debió aprehenderla conforme lo establecen los artículos 504,505 y 506 del Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero) y artículo 5.2.3, 5.2.3.4 y 5.3 de la Orden Administrativa 003 de 2010 de la Dirección de Gestión de Fiscalización DIAN.

Respecto a las conductas endilgadas, observa el despacho que los hechos sobre los cuales se basan las dos acusaciones refieren y tiene su origen en la diferencia de peso de la mercancía perteneciente a la empresa XXXXX en el acta de hechos elaborada por el investigado en el mes de diciembre de 2011 versus el acta de re inventario solicitada por que quejoso en el año 2012.

Encontrando a folios 1407 a 1410, el Auto N. 1017-240 del 18 de septiembre de 2012, por medio del cual la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, ordenó la terminación y consecuente

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

archivo de la investigación dentro del expediente administrativo disciplinario N. 213-303-2012-160, en contra del funcionario XXXXX, por los hechos irregulares relacionados con el acta de aprehensión acta 03-007 COMEX del 11 de enero de 2012, en relación con la diferencia existente entre el peso de la mercancía aprehendida con el que se relacionó en el Acta de Hechos No. 26166 de fecha 15 de diciembre de 2011, todo lo anterior respecto a la mercancía perteneciente a la empresa XXXXX

La mencionada decisión, se basó en imputar la diferencia de peso, al peso de las estibas con soporte de madera en que llega la mercancía la primera vez que se pesa, la cual podía ser de 10 kg por cada una de ellas, demostrándose de esta manera la diferencia de peso entre las actas de hechos del año 2011 realizada por el disciplinado XXXXX y la del año 2012 generada por^ solicitud de re inventario.

De igual manera, reposa en el acervo probatorio a folios 1260 a 1270 el Auto 17404-009 del 19 de diciembre de 2012, en este caso expedido por la Unidad Administrativa Especial Agencia del inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales ITRC, por medio del cual se ordenó la terminación y consecuente archivo de la investigación dentro del expediente administrativo disciplinario N.1704-01-2012-48, en contra del funcionario XXXXX, por las presuntas irregularidades en la diferencia de peso en el acta 03-007 con el acta realizada por el funcionario XXXXX, respecto a la mercancía de la empresa XXXXX.

En este caso el mismo fue terminado, teniendo en cuenta que las irregularidades que se investigaban ya habían sido base para decisión de archivo de la DIAN, generándose la institución de cosa juzgada.

Como se observa en los párrafos anteriores, para el despacho es claro que las conductas endilgadas en el Auto No. 17406-00010 del 7 de julio de 2016 al encartado XXXXX, se basan en los hechos investigados en el año 2012 por la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN dentro del expediente disciplinario N. 213-303-2012-160, por tanto, las conductas de las que se le acusan harían tránsito a cosa juzgada.

Para un mejor entender, la Corte Constitucional, en varias de sus sentencias definen la institución de cosa juzgada, así:

"La cosa juzgada es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones plasmadas en una sentencia y en algunas otras providencias, el carácter de inmutables, vinculantes y definitivas. Los citados efectos se conciben por disposición expresa del ordenamiento jurídico para lograr la terminación definitiva de controversias y alcanzar un estado de seguridad jurídica. De esta definición se derivan dos consecuencias importantes. En primer lugar, los efectos de la cosa juzgada se imponen por mandamiento constitucional o legal derivado de la voluntad del Estado, impidiendo al juez su libre determinación, y en segundo lugar, el objeto de la cosa juzgada consiste en dotar de un valor definitivo e inmutable a las providencias que determine el ordenamiento jurídico. Es decir, se prohíbe a los funcionarios judiciales, a las partes y eventualmente a la comunidad, volver a entablar el mismo litigio".

Es decir, queda claro que, en Derecho, no es procedente investigar dos veces la misma conducta, por tanto no existe ninguna posibilidad de sancionar al señor XXXXX, por unos hechos que ya fueron objeto de investigación y que terminaron en archivo de las diligencias, por consiguiente resulta claro que se debe absolver al investigado, al dar aplicación a la institución jurídica de la cosa juzgada.

B) En relación con el señor XXXXX.

"(...)como quiera que no denunció ante la autoridad correspondiente, la eventual falsedad ideológica cometida por el funcionario XXXXX con la expedición del documento público denominado Acta de Hechos No. 026166 de fecha 15 de diciembre de 2011, en relación con la Guía Máster No. 233-6077-6531, hecho del cual conoció, por lo menos, el 20 de febrero de 2012 cuando expidió el Acta Aclaratoria No. 5 de 20 de febrero de 2012, por medio de la cual se aclaró el Acta de Aprehensión No. 03-0007 COMEX"

Respecto a estos hechos, se encuentra a folios 1394 a 1395 el oficio 1-03-246-201-177 del 20 de febrero de 2012, suscrito por el señor XXXXX, Jefe de la División de Gestión de Carga de la Dirección Seccional de Aduanas Bogotá, dirigido al doctor XXXXX, Subdirector de Gestión de Control Disciplinario Interno, en donde dan a conocer las presuntas irregularidades relacionadas con la guía master 233-60776531, estando dentro de esta guía mercancía no relacionada y las presuntas irregularidades en el peso de la misma, mencionando al funcionario XXXXX.

Como se puede observar el oficio mencionado, el disciplinado XXXXX, en cumplimiento de sus funciones como servidor público, procedió de acuerdo a Derecho y en cumplimiento de sus deberes legales, ya que dio a

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

conocer los hechos que se presentaron a la oficina competente que podría determinar si existía una conducta irregularidad por parte de algún funcionario del grupo a su cargo.

Demostrándose así, que el aquí acusado realizó la denuncia correspondiente a quien tenía la competencia de investigar, por tanto, el hecho que le fue endilgado en el auto N. 17406-00010 del 7 de julio de 2016 no existió ya que el mismo realizó la denuncia correspondiente.

Por tanto, el despacho en la presente decisión ordenara la ABSOLUCION del señor XXXXX, al no encuadrarse su conducta en las presuntas irregularidades consideradas por el Despacho.

C) En relación con el señor XXXXX

"(...)como quiera que entre los meses de diciembre de 2011 y febrero de 2012, le solicitó al señor XXXXX, entonces Gerente sucursal Bogotá de la empresa XXXXX, la suma de \$100.000.000 para devolverle parte de la mercancía perteneciente a la Guía Máster No. 233-6077-6612, que había sido inmovilizada por la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá mediante Acta de Hechos No. 026372 de 17 de diciembre de 2011".

Respecto a estos hechos, es importante manifestar que la acusación hecha por el despacho, se basa en la información brindada por el quejoso XXXXX, quien adujo que el señor XXXXX, le solicitó una suma de dinero por la mercancía que le pertenecía, resaltando la unidad que dicha diligencia se tomó, cuando el señor XXXXX aún no estaba vinculado a la investigación siendo mencionado en la misma, por tal el mismo no pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, respecto a la prueba en que se basa su acusación.

Situación que llevo a que el apoderado del aquí disciplinado, requiriera que se escuchara en ampliación del quejoso, teniendo en cuenta la validez dada a dicha prueba por parte de la Subdirección de Investigación Disciplinarias de la ITRC, para así ejercer su derecho a la defensa, debido proceso y contradicción.

Procediendo de conformidad la presente subdirección, realizó requerimientos ante el RUT, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Policía Nacional de Colombia, entre otros, y así ubicar la dirección, teléfono del quejoso y dar cumplimiento a la prueba requerida por la defensa.

Adicional a lo anterior, la funcionaria de la entidad, se desplazó a varios sitios con el propósito de ubicarlo, incluida la ciudad de Cali, de igual forma tuvo comunicación verbal con el denunciante, quien jamás se presentó a las citaciones realizadas por la entidad, generando que la solicitud del apoderado del señor PADILLA no se pudiera llevar a cabo.

Entendiendo con lo anterior que el despacho realizó todos los tramites posibles, mas no como lo indica en sus aseveraciones el doctor XXXXX en su escrito de alegatos, en donde trata de afirmar que la SUBDIRECCION DE INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS ITRC, fue incapaz de practicar la prueba solicitada, ya que sobre este hecho se deben resaltar la infinidad de trámites que realizó la unidad para dar cumplimiento a lo requerido por la defensa, que si bien el quejoso no se presento fue por su negativa mas no porque el despacho hubiese sido negligente en su actuar.

Es entonces, que, ante la imposibilidad de escuchar en ampliación de queja al denunciante, el cargo endilgado al disciplinado se estaría basando en una prueba nula de pleno derecho, ya que dicha prueba como se ha mencionado se tomó sin la presencia del investigado vulnerando sus derechos al debido proceso, contradicción etc, por tanto, se hace necesario traer a colación lo relacionado con las pruebas en el proceso disciplinario, así:

"Cuando no sea posible la ratificación del medio de prueba, porque se han agotado las etapas procesales que permiten proceder de conformidad, se generara ilicitud probatoria del medio irregularmente incorporado, ya que las pruebas practicadas con vulneración del derecho a la contradicción probatoria son nulas de pleno derecho, y por ello inexistentes; en tales condiciones la prueba no podrá ser valorada como soporte de providencia alguna, y en tratándose de casos en que el medio probatorio ilícito es axial y constituye el único fundamento de la sentencia, será imperativo proferir en reemplazo el respectivo fallo absolutorio (Asuntos Disciplinarios. Pag. 290. Fernando Brito Ruiz y Francisco Farfan Molina"

De igual manera, en sentencias el Consejo de Estado, se menciona lo relacionado con la NULIDAD DE PLENO DERECHO de las Pruebas obtenidas con vulneración de derechos fundamentales:

"Frente a la consideración de la Sala Penal según la cual la grabación que se hizo valer en el proceso fue convalidada por el imputado al haber admitido en la indagatoria que la reunión videograbada era

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

la que sostuvo en Yopal, esta Sala debe precisar que la nulidad de pleno derecho que establece la Constitución como consecuencia de haberse recaudado la prueba con violación de derechos fundamentales impide considerarla válidamente en el proceso, así el demandante admita que esa prueba consigna hechos que se le endilgan en el proceso penal. La Corte Constitucional reitera en este punto que la inconstitucionalidad de la prueba impide considerarla válidamente en el proceso penal, pese a su convalidación por parte del procesado. En este punto debe ponerse de relieve que la frase utilizada por la Carta es la de "nulidad de pleno derecho", expresión que indica la improcedencia de la convalidación por afectación absoluta o radical de la validez del acto.

De tal importancia es la protección de los derechos de los investigados, que la Constitución Política de Colombia también nos habla de la prueba nula de pleno derecho, consagrada en su artículo 29, la cual entronizó en el ámbito nacional la regla de exclusión de la prueba ilícita, disponiendo en el artículo 29 de la norma superior que:

"es nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación del debido proceso".

Otorgando especial trascendencia al concepto de debido proceso, tanto en lo formal como en lo material, lo que implica que las afectaciones a los mismos, en lo que concierne a la aportación de medios de prueba de índole ilegítimos, cuando ello produce una infracción de carácter sustancial, daría lugar a la aplicación al mandato del artículo 29 constitucional, la nulidad de pleno derecho y por tanto su exclusión del proceso. Ahora, en el artículo 6 de la Ley 1123 de 2007, tema regulado en el mismo artículo de la ley 734 de 2002, determina que:

"El sujeto disciplinable deberá ser investigado por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que determinen la ritualidad del proceso".

La mención expresa del legislador al tema del debido proceso material, sin lugar a dudas es darle relevancia a ese derecho fundamental para impregnarlo de los mismos efectos que produce su desconocimiento.

La misma Ley en su artículo 140, menciona la Inexistencia de la prueba recaudada sin el lleno de las formalidades sustanciales o con desconocimiento de los derechos fundamentales del investigado, se tendrá como inexistente.

Respecto a la prueba para sancionar consagrada en el artículo 142 de la Ley 734 de 2002 indica que no se podrá proferir fallo sancionatorio sin que obre en el proceso prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del investigado.

Así pues, después de analizar lo antes descrito, no es procedente generar una sanción por la acusación en contra del señor XXXXX, teniendo en cuenta que la misma se basa en una prueba que según lo visto es NULA DE PLENO DERECHO, al haberse practicado sin la presencia del investigado, impidiéndole ejercer su derecho a controvertirla misma, situación que con llevo a que la defensa la requiriera en el desarrollo del proceso, sin llevarse a cabo por la negativa del quejoso.

Por tanto, este cargo queda sin sustento legal, al ser la prueba que soporta el mismo, una prueba inexistente y por tal no podrá ser soporte para una sanción, generando que el despacho proceda en derecho y ordene la ABSOLUCION del señor XXXXX.

Por último, en relación con la solicitud de versión libre, como se observa en el presente acto administrativo estamos absolviendo al señor XXXXX, por tanto no resulta necesario que rinda diligencia de versión libre, ya que el proceso falla a su favor.

En mérito de lo expuesto, el Subdirector de Investigaciones Disciplinarias de la Unidad Administrativa Especial Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales,

RESUELVE

PRIMERO: ABSOLVER a los señores XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXX, en su cargo de Gestor III Código 303 Grado 03 XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número XXXXX, con el cargo de Facilitador IV Código 104 Grado 04, XXXXX, identificado con cédula de ciudadanía número 79.670.796, con el cargo de Analista II Código 202 Grado 02, todos pertenecientes a la División de Gestión Control Carga de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, del cargo imputado en decisión No. 17406-00010 del 7 de julio de 2016, acorde con las razones expuestas.

POR MEDIO DEL LA CUAL SE PROFIERE FALLO DE PRIMERA INSTANCIA DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DISCIPLINARIO No. 1704-01-2012-072

SEGUNDO: NOTIFICAR PERSONALMENTE la presente decisión de conformidad con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 734 de 2002, al señor XXXXXX, en la XXXXX Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y a su abogado XXXXX (abogadojepadilla@gmail.com), al señor XXXXX en la XXXXX, teléfono XXXXX y/o en la XXXXX de Exportaciones- División de Gestión de la Operación Aduanera Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y a su abogada XXXXX a la XXXXX, al señor XXXXX en la XXXXX y a su abogado XXXXX a la XXXXX.

TERCERO: COMUNICAR la presente decisión al señor XXXXX, al correo electrónico XXXXX y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 Ibídem.

CUARTO: ADVERTIR que contra la presente decisión procede el RECURSO DE APELACIÓN en el efecto suspensivo, al tenor de los Artículos 111, 112 y 115 ibídem, que, de considerarse, deberá interponerse y sustentarse dentro de los tres días siguientes a la notificación.

QUINTO: INFORMAR, una vez en firme la presente decisión a la Procuraduría General de la Nación, en orden a que se produzcan las anotaciones a que haya lugar.

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE y CÚMPLASE,



JORGE ADRIANO MORENO PONCE
Subdirector de Investigaciones Disciplinarias
UAE Agencia ITRC